

1501294-80.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501294-80.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267107/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27760708 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2267107 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

MARCIO RAMOS PESSOA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III, VI e Art. 35 "caput" todos do(a)

SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

23/11/2022

Réu Preso

Em 23 de novembro de 2022, às 16:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu MARCIO RAMOS PESSOA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Rudnei de Souza OAB 438846/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas de acusação Eduardo Leopoldo Ambold (GCM) e Daniel Adriano Vieira (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de

videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu MARCIO RAMOS PESSOA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 29 de setembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, se associou com o adolescente Weberton Alves Lopes (17 anos de idade), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 20h18, na Rua Lucia Rodrigues Bertin, nº 98 - Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, nas proximidades de escolas e de postos de saúde (fls.6 e 7), previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos com o adolescente Weberton Alves Lopes (17 anos de idade), guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 1 porção a granel de cocaína, com peso bruto aproximado de 38 gramas, 2 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 3 gramas, 417 porções de cocaína ("aricanduva"), com peso bruto aproximado de 413 gramas, e 331 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 219 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado e o adolescente se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, dividiam as tarefas na empreitada criminosa. Na prática delitiva, MARCOS e o adolescente faziam uso do imóvel localizado no endereço acima mencionado, onde guardavam, mantinham em depósito, pesavam, separavam e embalavam drogas para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Municipais estavam em serviço, efetuando patrulhamento em prédios públicos avistaram MARCIO - conhecido nos meios policiais - saindo do imóvel localizado na Rua Lucia Rodrigues Bertin, nº 98. Ao perceber a aproximação da viatura, MARCIO apresentou comportamento evasivo, reagindo à presença da guarnição correndo para dentro da residência. Diante disso, os Guardas deliberaram pela abordagem, tendo em vista notícias anteriores de que o acusado utilizava "uma casa" naquele bairro para "armazenar e dividir" drogas com finalidade mercantil, local conhecido como "Casa Bomba". Assim é que, de imediato, os Guardas seguiram no encalço de MARCIO e o alcançaram na garagem do imóvel. Ao ser abordado, o acusado logo disse: "perdi, senhor!". Durante a abordagem, os Guardas avistaram o adolescente Weberton, que estava na sala do imóvel embalando drogas. Indagado, MARCIO admitiu a prática delitiva e informou que havia adquirido as drogas em Sorocaba, para posterior distribuição em Tatuí, o que fazia com o envolvimento e associação do adolescente. No local, os Guardas apreenderam 331 "pinos" de cocaína, 417 porções de cocaína ("aricanduva"), 2 porções de "maconha" e 1 porção de cocaína a granel, drogas que pertenciam ao denunciado e estavam destinadas ao tráfico ilícito, que MARCIO praticava no local, associado com o adolescente, além de 1 balança de precisão, de 2 facas, de 1 colher, de 1 tesoura, de 1 peneira, de 1 rolo de plástico filme - objetos comumente utilizados para se pesar, separar e embalar drogas - e da importância de R\$ 254,80 em espécie, dinheiro angariado com a prática da mercancia ilícita. Durante as buscas, os agentes públicos ainda encontraram 1 aparelho de telefone celular. O réu foi notificado (fls. 241) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 95/124). Assim, por decisão proferida no dia 09 de novembro de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 242/246). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. De outra banda, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela concessão de todos os benefícios legais a incidir em fase de dosimetria da pena e

fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 29/30, bem como certidões a fls. 31/33. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. I – DAS PRELIMINARES: De início, antes de ingressar na matéria meritória, cabe analisar as preliminares arguidas pela Defesa. Da Legitimidade da Atuação da Guarda: Faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, distintamente do alegado pelo D. Defensor, os guardas civis municipais, na data dos fatos, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). E nesse patrulhamento rotineiro, encontraram o acusado, o qual já era conhecido dos meios policiais e apresentou comportamento suspeito, oportunidade em que encontraram, na residência onde estava, grande quantidade de drogas e o adolescente Weberton embalando drogas, no que consistiu o estado flagrancial. Como se vê, os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Até porque, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de “qualquer pessoa do povo” seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, “qualquer do povo” poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13.022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de “garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas”, consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. Da Legalidade Busca Domiciliar: E mais, cabe destacar que o postulado constitucional da inviolabilidade do lar não é direito fundamental absoluto. Aliás, segundo entendimento doutrinário majoritário, nenhum direito ou garantia fundamental o é, comportando relativizações proporcionais e razoáveis. Quanto ao direito fundamental em questão, o próprio constituinte originário, ao assegurar a inviolabilidade do lar, relativizou-o, dispondo sobre situações excepcionais que se a busca domiciliar sem o consentimento do morador e sem autorização judicial, entre as quais está o estado

flagrancial. Vejamos: “Art. 5º (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)” (grifos aditados). Na espécie, em se tratando, o delito de tráfico de entorpecentes, de crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o estado flagrancial se estende até que sobrevenha a interrupção da execução criminosa, na forma do art. 303 do CPP. Assim, durante o lapso temporal em que se protraí a prática do tráfico e, conseqüentemente, o estado flagrancial, é lícito a busca domiciliar, ainda que sem autorização judicial ou consentimento do morador, com amparo na exceção constitucional de flagrante delito. No entanto, para evitar abusos, o C. STF consolidou o entendimento que a busca domiciliar nesses

casos deve ser submetida a um controle jurisdicional posterior, onde se examina se existia, ex ante ao ingresso, justa causa para tanto, devidamente justificada pelos agentes públicos (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). In casu, como se verá posteriormente, havia notitia criminis inqualificada da prática do comércio de drogas e o acusado foi visto em atitude suspeita, o que, indiscutivelmente, constitui justa causa para a busca domiciliar. Em assim sendo, não houve qualquer ilegalidade a ensejar o reconhecimento da nulidade das provas, restando afastada a preliminar suscitada pela Defesa. II – DO MÉRITO: Superada a questão preliminar, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido acusatório comporta parcial procedência. De fato, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelas razões que passo a expor. A despeito da majorante em questão ter natureza objetiva e, portanto, dispensar a intenção do traficante de captar sua clientela junto aos frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal supra citado, tem-se que, para não gerar responsabilidade penal objetiva, exige-se que haja concentração de pessoas nas proximidades e adjacências daquele lugar para justificar a incidência da causa de aumento especial em tela. Ora, a ratio da norma visa exasperar a pena de pessoa que se aproveita da aglomeração de pessoas nas proximidades daquele local, facilitando a ocultação e evasão do traficante. In casu, como os fatos se deram durante o período noturno e a escola apontada a fls. 06/07 tem horário de funcionamento diurno, estando, portanto, fechada. E, conseqüentemente, não havia concentração de pessoas a justificar a incidência da causa de aumento em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). E mais, quanto a igreja apontada a fls. 92, é necessário considerar que o local dos fatos distava mais de 260 metros da unidade de ensino indicada na exordial e, portanto, não se enquadram no conceito de adjacências, ou mesmo proximidades. Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: “No entanto, respeitada a compreensão diversa da Juíza sentenciante, entendo necessário o afastamento do último aumento, sob pena de responsabilidade objetiva do réu. Inicialmente, porque as distâncias indicadas no relatório de investigação de fls. 38/39 deixam claro que o local em que o acusado foi abordado não era realmente próximo de nenhum daqueles mencionados em referido documento (290 metros da escola "Professora Vera Vitali" e Quadra Poliesportiva Anexa; 110 metros da Creche e Pré-Escola Nilce Fugió Takassi; 240 metros do Centro Esportivo Waldemar Moreira; e 400 metros da USF José Adalberto Lellis Garcia e Centro de Lazer do Bairro Antônio Garcia). Em segundo lugar, porque a abordagem se deu por volta de 20h00, e o local mais próximo, a Creche e Pré-Escola, certamente estava fechada nesse horário. E, em terceiro lugar, porque não houve campana, a fim de demonstrar que os frequentadores de tais ambientes adquiriam entorpecente do apelante. Fica, portanto, afastada referida causa de aumento” (TJSP; Apelação Criminal 0001264-77.2018.8.26.0210; Relator (a): Nelson

Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/03/2014; Data de Registro: 05/05/2020). Afastada, pois, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, também deve-se absolver o réu da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...) (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...) (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...) (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e o adolescente exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. É dizer, não há dúvidas de que o réu exercia com o adolescente o tráfico de drogas e que essa ação criminosa era duradoura, seja pela apreensão de instrumentos para a preparação de drogas, seja pela localização de vultosa quantidade de entorpecentes. O que é duvidoso é se a participação do adolescente era episódica e casual ou se havia animus associatatis, ou seja, se havia intenção do acusado de, permanentemente ou estavelmente, exercer o tráfico de drogas com o auxílio do menor. Isto porque não houve prévia investigação policial onde fosse possível verificar que o tráfico exercido com o adolescente não foi pontualmente, revelando o caráter não episódico da traficância com o auxílio do menor. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o acusado e o adolescente, imperiosa a absolvição do réu no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 24/27), pelo auto de exibição e apreensão (fls.

08/09), pelo auto de constatação preliminar (fls. 05), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/91) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 12), afirmou que, na data dos fatos, estava dormindo na residência e que a casa onde estava, era moradia de seu tio Lineu, que está preso. Alegou desconhecer a procedência das drogas localizadas pelo local e que estava com seu colega Weberton, que também dormia. Não pratica atualmente tráfico de drogas, mas já foi "preso" por tráfico anteriormente, quando menor de idade. Esclarece que, na data dos fatos, juntamente com Weberton, fizeram uso de maconha e dormiram pelo local. Perguntado pelo defensor se já havia sido abordado por essa guarnição, alegou que sim. Diz que compra maconha na Vila Angélica, porém não soube especificar o endereço exato. Em juízo disse que realmente estava com a droga em sua casa. Mas nega que viu os policiais e correu para dentro da casa. Os policiais arrombaram a droga e entraram no local. Não foi pego na garagem e sim dentro da casa. Também não é verdade que pertence a grupo criminoso. O portão estava trancado, mas era bem fraco, daí eles pular num corredor que dá acesso a garagem e entraram na casa. Eles arrombaram a porta, daí ficou com medo e explicou para o menor o que estava acontecendo, pois o menor não sabia da droga. Era pago para guardar a droga dentro da casa e o menor não sabia. É amigo de escola do adolescente e estavam juntos mexendo no celular. A droga - aricanduva estava dentro de uma lata que guarda arroz e os pinos estavam no chão. A maconha era para seu uso. Os pinos estavam atrás do sofá e estavam cheios. O menor não ajudava em nada. Estava armazenado há um mês, pois estava desempregado. Tem 18 anos e não tem filhos. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - verifica-se que o acusado assumiu a prática do tráfico, negando a participação do adolescente e trazendo versão diversa quanto a abordagem dos guardas municipais. De outro lado, a prova dos autos revela cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas nos exatos termos constantes na denuncia. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 06), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelos prédios públicos municipais (escola, creches, pré-escola e posto de saúde) do Bairro Vila Angélica. Naquela ocasião, avistaram o réu, que já é conhecido nos meios policiais, oportunidade em que o acusado estava saindo de uma residência. A equipe tinha informações que o acusado utilizava de uma casa no mesmo bairro para armazenar e dividir em porções as drogas para serem comercializados no bairro. Conhecido como casa BOMBA, o acusado, ao perceber aproximação da viatura mudou de comportamento e saiu em fuga para o interior da residência. Então, a equipe desembarcou e acompanhou o réu. Ao entrar na garagem, abordaram o acusado, que, de imediato, falou "perdi senhor" (SIC). Em seguida, avistaram Weberton sentado na sala embalando drogas. Indagados, ambos confessaram o tráfico de drogas. O acusado falou para a equipe que comprou a droga na cidade de Sorocaba, para ser comercializados no local dos fatos. Na casa, foram localizados 331 pinos de cocaína, 417 porções de cocaína tipo aricanduva, 02 porções de maconha, 1 porção de cocaína a granel, balança de precisão, 2 facas 1 colher, 1 tesoura 1 peneira 1 aparelho celular 1 rolo de papel filme e a quantia de R\$118,85. Em juízo disse que estavam em patrulhamento na rua da escola e tinham informações do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes e que teria alugado uma casa para tanto, onde manipulava os entorpecentes para depois distribuí-los. Visualizaram o réu saindo da residência e ao avistar a viatura correu para o interior da residência e disse "perdeu". No local encontraram o adolescente com um prato em sua frente embalando os entorpecentes. Fizeram revista no menor e encontraram entorpecentes, balança, faca, papel filme, dinheiro e um aparelho de celular. Havia pertences de Marcio no local e ele confirmou que estava morando no local. Já havia conduzido o réu umas 3, 4 vezes quando esse era adolescente, pelo suposto envolvimento com o tráfico. O local é passagem para passar pela escola e a casa fica próxima a escola, cerca de um a dois quarteirões. Em linha reta não daria 200 metros. Perguntas da defesa - o que os fez ingressar na residência foi a conduta do réu de avistar a viatura e correr para dentro da casa, bem como tinham denuncia anônima do réu. Adolescente e réu admitiram o tráfico, e o réu disse que havia adquirido a droga em Sorocaba. Não

chegou a perguntar a quanto tempo o réu estava traficando, mas sabem que há bastante tempo pois em uma apreensão de tráfico feita anteriormente, o indivíduo disse que estava guardando droga para Marcio. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Daniel Adriano Vieira, em solo policial (fls. 07), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro aos arredores de igreja, escola e avistaram o indivíduo Marcio, sempre que tinham informação que o réu tinha comprado uma parte da biqueira para vender drogas, que ele seria patrão e teria se batizado ao PCC e alugou uma casa para armazenar, picar e dividir em porções entorpecentes para dividir no bairro. Quando desembarcaram e saíram a procura do réu, este ingressou na residência e disse "perdi, perdi". No interior da residência encontraram o adolescente manuseando o entorpecente. No local foi encontrado balança, papel filme, tudo para o embalo da droga. Já conhecia o réu pelo próprio crime de tráfico, por mais de uma vez. Nesse período também chegou a informação de que Marcio havia virado patrão de uma parte da vila. Isso acontecia desde a adolescência do réu. O réu já dizia "perdi" e disse que a droga estava toda "ali". Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas na residência em que o acusado estava; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/91), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente ("Item I - Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores. Itens II, III e IV - Utilizando-se metodologias adequadas para análises dos referidos materiais, foram detectadas a presença da substância Cocaína, constante na lista F1: Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores" - fls. 90) (grifos aditados). Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a localização do acusado em local onde informação anônima descrevia que ele estaria traficando drogas, correspondendo exatamente a situação flagrada pelos policiais; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo de drogas; 5) a apreensão de inúmeros apetrechos utilizados para a preparação e fracionamento de drogas (balança de precisão, 2 facas, 1 colher, 1 tesoura, 1 peneira e 1 rolo de papel filme - fls. 08/09); e 6) a informações dos guardas, de que, informalmente, o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas, precisando, inclusive, a cidade onde comprou o entorpecente, Sorocaba/SP. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação

0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 87/91) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - guardar e manter em depósito -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. E mais, tendo o acusado cometido o crime de tráfico de entorpecentes em companhia do adolescente Weberton, segundo depoimento dos policiais, deve incidir a causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, dado o envolvimento da menor na traficância. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena

a ser lhes imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, deve-se considerar nesse ensejo a maior culpabilidade de sua conduta, revelada pela grande quantidade e diversidade de entorpecentes (1 porção de cocaína, com 38 gramas, 2 porções de "maconha", com peso de 3 gramas, 417 porções de cocaína, com peso de 413 gramas, e 331 porções de cocaína, com peso de 219 gramas), o que expande o universo de usuários atingidos pelo tráfico realizado pelo réu e incrementa a lesão ao bem jurídico, saúde pública, aqui tutelado. Desse modo, é de rigor a fixação da pena-base 1/6 (ante a presença de duas circunstâncias desfavoráveis) acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, deve-se considerar que se trata de réu que possuía menos de 21 anos à época dos fatos e, portanto, presente a circunstância atenuante de menoridade relativa, bem como da confissão. Por essa razão, atenuo sua pena até o mínimo legal, isso é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em terceira fase, existente a majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento sua pena na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tem-se que sua incidência restou inviável. De fato, esse redutor legal reclama, para sua aplicação, a presença dos requisitos subjetivos cumulativos de primariedade, ausência de antecedentes, não integração à organização criminosa ou dedicação à atividades delitivas. Isso porque, a despeito da primariedade do acusado, tem-se que a vultosa quantidade de drogas (1 porção de cocaína, com 38 gramas, 2 porções de "maconha", com peso de 3 gramas, 417 porções de cocaína, com peso de 413 gramas, e 331 porções de cocaína, com peso de 219 gramas), revela empreitada criminosa ousada, o que demonstra sua dedicação à atividades criminosas. Até porque, certamente, um traficante não entregaria tamanha quantidade de drogas para alguém que nunca ostentou qualquer envolvimento anterior com a criminalidade. Para angaria a confiança do traficante, indubitavelmente o réu já estava inserido no universo criminoso. E disso não há qualquer desrespeito ao ordenamento jurídico pátrio. Pelo contrário, é assente, na jurisprudência do STJ, que : "a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas" (AgRg no REsp 1442055/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015). Aliás, em caso análogo decidiu que: "No contexto, considerando os dados explicitamente admitidos na sentença e repisados no acórdão recorrido, num exercício de reavaliação do acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias, levando em conta o transporte, em fundo falso do caminhão, de cerca 1,5t (uma tonelada e meia) de maconha, acondicionados em tablets envoltos em plástico, é possível concluir que o acusado, não obstante seja tecnicamente primário, dedicava-se a atividades delituosas. Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, que evidenciam a dedicação do acusado a atividade criminosa, de rigor que se afaste a causa especial de diminuição de pena" (REsp nº 1.611.719/GO Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/10/2017, DJe 13/10/2017). Mas não é só! Para além, também deve-se destacar que o acusado possui inúmeros antecedentes infracionais (fls. 32/33), demonstrando sua propensão ao exercício de atividades ilícitas (fls. 25/26). A propósito, assim é a jurisprudência do C. STJ: "o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas" (HC n. 435.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018). Como se vê, é evidente a dedicação do réu a atividades criminosas, legitimando o afastamento da "privilegiadora" do tráfico de drogas. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena

no regime fechado, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo tráfico de enorme quantidade de entorpecente de forma interestadual e com o auxílio de adolescente. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis ou dos benefícios previstos no art. 44 do CP. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) afastando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, para condenar o réu MARCIO RAMOS PESSOA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver o réu da imputação de prática do crime previsto artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, trata-se de réu que desde sua adolescência se dedica a prática de atos infracionais, como se depreende da certidão de fls. 32/33, de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir. Para além, deve-se considerar a quantidade de entorpecente, o que revela a propensão do réu a reiteração de atividades delitivas. Por essas razões, a manutenção de sua prisão cautelar do réu é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado, signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 68) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 118,25 em dinheiro - fls. 93) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminoso. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais apreendidos, considerando que eram utilizados para a prática do tráfico de drogas e, portanto, são instrumentos do crime para o exercício habitual da traficância, também determino seu perdimento, com escopo no art. 61 da Lei nº 11.343/06. Se não houver interesse em perdimento dos bens apreendidos, destrua-se esses na forma do que preceitua os art. 124 do CPP". Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos

demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA